

제24장

전문심리위원 제도

-
- 제1절 총 설 790
- 제2절 전문심리위원의 참여 794
- 제3절 전문심리위원 참여결정의 취소 807
- 제4절 전문심리위원의 제척 및 기피 809
- 제5절 수명법관 등의 권한,
비밀누설죄 등 812

제1절 총 설

1. 의 의

전문심리위원 제도는 지식재산권, 건축, 노동, 의료, 상사, 환경 등 전문적인 지식이 요구되는 사건에서 법원 외부의 관련 분야 전문가를 전문심리위원으로서 소송절차에 참여하게 하여 전문적인 지식과 경험에 기초한 설명이나 의견을 들음으로써 충실한 심리와 신속한 분쟁해결에 도움을 받는 제도이다.

전문심리위원을 소송절차에 참여하게 하는 목적은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차를 원활하게 진행하기 위해서이다(민소 164조의2 1항). 소송관계를 분명하게 하기 위한 구체적인 경우는, 건설관계·의료관계 소송 등에서 당사자의 공사 하자 주장·의료과실 주장이 분명하지 아니한 경우, 전문적인 용어·도면 등이 포함된 많은 서증이 제출되어 당사자의 청구 내용을 쉽게 이해하기 어려운 경우 등이다. 소송절차를 원활하게 진행하기 위한 구체적인 경우는, 특수하고 복잡한 사안에 대한 감정 가능성 판단, 감정신청의 적정성 판단, 감정사항의 확정 등과 관련하여 신속한 감정절차 진행을 위하여 전문심리위원의 설명이나 의견을 들을 필요가 있는 경우 등이다. 소송관계를 분명하게 하기 위하여 석명처분(민소 140조)을 할 수 있지만, 보다 신속하고 효율적인 방법의 하나로 전문심리위원 제도를 이용할 수도 있다.

개정 전문심리위원규칙(2025. 1. 1. 시행)은 법원행정처장이 감정관리위원을 위촉하여 감정채부, 감정인 선정, 감정사항 검토, 감정인 업무 감독 등 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행하도록 하고, 감정관리위원으로 하여금 후술할 상임전문심리위원을 상호 겸할 수 있도록 하였다(2조의4).

2. 전문심리위원 제도 도입의 경과

2007년 민사소송법 개정으로 2007. 8. 14.부터 전문심리위원 제도가 시행되게 되었고, ‘상임전문심리위원’ 제도는 2016. 11. 1. 전문심리위원규칙 2조의2, 2조의3을 신설하면서 도입되었으며, 앞서 본 바와 같이 2025. 1. 1. 시행된 전문심리위원규칙(2조의4, 2조의5)에 따라 상임전문심리위원을 겸임하면서 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행하는 감정관리위원 제도도 도입되었다.

3. 전문심리위원의 역할

특정한 사건에 관하여 전문심리위원으로 지정되어 해당 사건의 소송절차에 참여하게 되고, 원칙적으로 그 소송이 종료할 때까지 참여하게 된다. 전문심리위원은 참여하는 사건에서 전문적인 지식과 경험을 필요로 하는 사항에 관하여 설명 또는 의견을 적은 서면을 제출하거나, 기일에 출석하여 구두로 설명 등을 하게 된다. 위 방식들 중 한 가지 또는 두 가지 방식 모두에 의하여 참여할 수 있다.

4. 다른 전문가 제도와의 비교

가. 감정인과의 비교

감정은 법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 자로 하여금 법규나 경험칙 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실판단을 법원에 보고하게 하는 증거조사이다. 감정을 할 때는 감정사항을 명확히 하여야 하고 감정인에게 선서의무를 부여하나, 전문심리위원에 대하여는 설명 등 요구사항을 감정사항과 같이 명확히 확정할 필요가 없으며, 감정에 비하여 신속한 도움을 받을 수 있는 장점이 있다. 다만 감정 결과는 증거자료가 되지만, 전문심리위원의 설명 등은 증거자료가 되지 아니한다.

나. 기술심리관과의 비교

특허법원 기술심리관은 4급 또는 5급의 법원공무원 또는 파견된 공무원으로 보하고(기술심리관규칙 2조 1항), 법원은 결정으로 특허, 실용신안, 디자인 관계 소송의 심리에 참여하게 할 수 있으며(법조 54조의2 2항), 기술심리관은 재판장의 허가를 받아 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있고, 재판의 합의에서 의견을 진술할 수도 있다(3항).

이와 비교하여 전문심리위원은 신분상 공무원이 아니고, 재판의 합의에 참여할 수 없다.

다. 상고심의 참고인

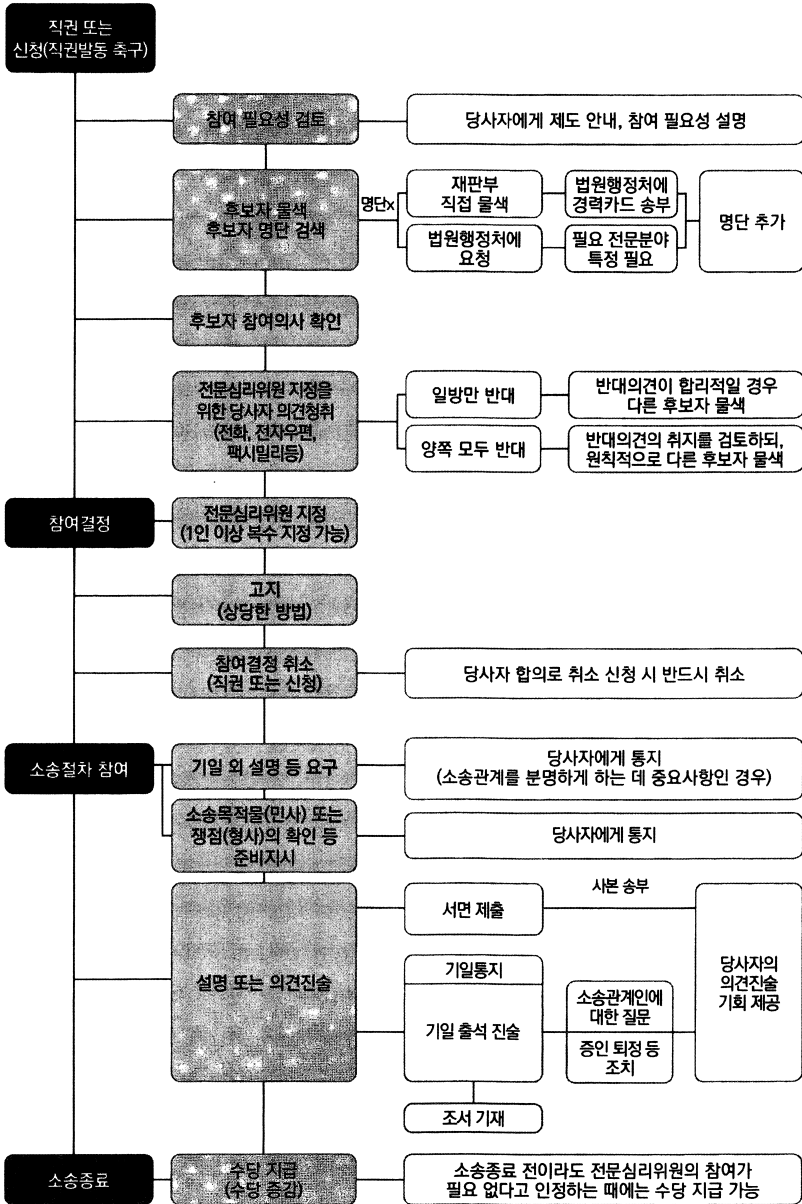
상고법원은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 필요한 경우에는 특정한 사항에 관하여 변론을 열어 참고인의 진술을 들을 수 있다(민소 430조 2항). 그러나 위 상고심의 참고인 제도는 변론을 여는 경우에 한하여 활용될 수 있고, 참고인의 경우 반드시 중립적인 위치에 있는 자만으로 한정될 필요가 없어 당사자가 자신에게 유리한 진술을 해 줄 사람을 참고인으로 채택해줄 것을 요청할 수 있다는 점에서는 전문심리위원 제도와 다르다.

라. 사실조회

민사소송법상의 사실조회절차를 통해서도 전문가의 의견을 들을 수 있다. 다만 사실조회공문의 발송과 사실조회회보서의 수신을 거쳐야 하므로 빠르게 전문가의 의견을 듣기 어려운 시간적 난점이 있고, 그 조회결과가 항상 충실하다거나 전문성이 보장된다고 보기 어려운 측면이 있다.

5. 소송절차 참여에 관한 개괄적인 흐름도

전문심리위원의 소송절차 참여에 관한 개괄적인 흐름은 아래와 같다.



제24장

전문심리위원 제도

상임전문심리위원의 경우 고등법원 단위로 상근하고 있으므로 재판부가 상임전문심리위원을 전문심리위원으로 지정하고자 할 경우 후보자 물색에 있어 상대적으로 용이할 수 있다. 또한 감정관리위원의 경우 해당 재판부 관

할 고등법원 감정관리센터의 감정관리위원을 전문심리위원으로 선정하게 되고, 선정된 감정관리위원은 감정절차 관리업무를 수행하게 된다는 점에서 특색이 있다.

제2절 전문심리위원의 참여

1. 전문심리위원의 참여 요건

가. 직권 또는 당사자의 신청

법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다(민소 164조의2 1항). 전문심리위원은 소송절차의 진행에 관하여 법원의 보조자로서의 성질을 가지고, 전문심리위원의 설명 등이 증거자료가 되는 것이 아니므로 전문심리위원 참여 결정은 법원이 직권으로 결정한다. 따라서 당사자의 신청은 법원의 직권 발동을 촉구하는 것에 불과하다.

나. 참여할 수 있는 소송절차

전문심리위원은 민사, 형사, 가사, 행정, 특허 등 소송절차에 참여할 수 있고(전문심리예규 2조), 심급의 제한이 없다. 다만 상임전문심리위원과 감정관리위원은 형사소송절차에 참여할 수 없다(전심규 2조의2 1항, 2조의4 1항).

전문심리위원은 증거조사, 화해 등을 포함한 소송절차의 모든 단계에 참여할 수 있다. 쟁점정리기일, 증인신문기일, 화해기일, 현장검증기일, 감정인신문기일 등에 참여하여 전문적 지식에 근거한 설명 등을 할 수 있고 설명 등을 기재한 서면만을 제출할 수도 있다.

전문심리위원이 참여할 수 있는 사건의 종류에는 제한이 없다. 건설, 의료, 지식재산권 사건, 소프트웨어 개발 관련 손해배상 청구 사건, 자동차 기

타 각종 기제의 설계·구조에 관한 손해배상 청구 사건, 화재의 원인과 관련된 사건 등 전문적 지식과 경험이 필요한 사건 등이 전문심리위원이 참여할 수 있는 사건에 해당한다.

다. 참여의 필요성

(1) 소송관계를 분명하게 하기 위하여

소송관계는 청구, 주장 및 증명에 관한 모든 사항을 의미하므로, 소송관계를 분명하게 하기 위한 경우는, 당사자의 청구, 주장 및 증명에 관한 모든 사항 중에서 분명하지 아니한 사항이 있는 경우이다. 당사자가 주장하는 내용(하자 주장, 의료과실 주장, 상표권 침해 주장 등), 제출한 서증 등의 의미를 명확하게 할 필요가 있는 경우가 이에 해당할 것이다.

(2) 소송절차를 원활하게 진행하기 위하여

소송절차를 원활하게 진행하기 위하여 필요한 경우는, 심리의 진행방법과 증거조사의 시기와 범위 등을 위하여 전문적 식견이 필요한 경우이다. 이와 관련하여 개정 전문심리위원규칙(2025. 1. 1. 시행)에서는 상임전문심리위원을 겸하면서 감정채부, 감정인 선정, 감정사항 검토, 감정인 업무 감독 등 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행할 감정관리위원 제도를 도입하였다(2조의4).

(3) 참여 필요성 검토

전문심리위원을 참여하게 할 것인지 여부는 소송절차 진행에 관한 재량에 속하고, 그 필요성 판단은 사안과 상황에 적합한 것이어야 한다. 참여 필요성이 인정될 경우 당사자에게 전문심리위원 제도를 안내하고[전산양식 A1953 참조], 참여의 필요성을 설명하는 것이 바람직하다.

2. 전문심리위원의 참여 과정

가. 전문심리위원 후보자 명단 작성

법원행정처장은 국가기관, 공공단체, 교육기관, 연구기관 등에 대한 추천 의뢰 혹은 법원 홈페이지에 공고를 하는 방법 등으로 전문심리위원 후보자 명단에 등재할 전문가를 물색하여 후보자를 정하고 그 명단을 작성하여야 하고(전문심리예규 3조 1항, 2항), 전문심리위원 후보자로부터 경력카드[전산양식 A1960]를 제출받아 전문심리위원 후보자 명단과 함께 관리한다(4항). 후보자 명단을 작성한 때에는 후보자 명단에 등재된 사람 및 그 후보자를 추천한 기관 또는 단체에게 후보자 명단에 등재된 사실을 통지[전산양식 A1965(기관용), A1966(개인용)]한다(6항).

법원은 위 후보자 중에서 전문심리위원을 지정하여야 한다(민소규 38조의 2). 후보자 명단에서 적절한 후보자를 찾을 수 없는 경우가 있을 수 있는데, 해당 재판부는 법원행정처장에게 새로운 후보자를 명단에 추가하여 줄 것을 요청할 수 있고, 법원행정처장은 그와 같은 추가 요청 또는 그 밖의 사정에 따라 추가가 필요하다고 인정할 경우에는 언제든지 새로운 전문심리위원 후보자를 정할 수 있다(전문심리예규 3조 1항 단서).

나. 전문심리위원 지정을 위한 의견청취와 참여결정

전문심리위원을 지정하기 전에는 당사자의 의견을 들어야 한다(민소 164조의4 1항). 법원은 전문심리위원의 참여가 필요하다고 판단할 경우 전문심리위원 후보자 명단에서 후보자를 검색·선정하여 그 후보자에게 참여할 수 있는지 여부를 확인한 다음, 전자우편 또는 팩시밀리 등을 활용하여 양쪽 당사자에게 그 후보자의 이름, 전문분야, 경력 등을 기재한 의견청취서[전산양식 A1940, B2301]를 보내거나 그 밖의 적절한 방법으로 후보자를 전문심리위원으로 지정하는 것에 대한 당사자의 의견을 들어야 한다(전문심리예규 4조 1항). 여기에서 의견이란 전문심리위원 참여 자체에 대한 것이 아니라 특정

한 전문심리위원 후보자를 전문심리위원으로 지정하는 것에 대한 의견이다. 당사자가 실제로 의견을 제시하여야 전문심리위원을 지정할 수 있는 것은 아니고 당사자에게 의견을 표시할 기회를 주는 것으로 충분하다.

당사자가 서면에 의하지 않고 전문심리위원 지정에 관한 의견을 표시하는 경우 법원사무관 등은 조서에 그 의견을 기재하거나 의견청취서 등에 의견 청취 방법과 의견의 취지를 적는 방식(예컨대, 2025. ○. ○. 전화로 청취, 전문심리위원 지정에 관하여 양쪽 당사자 동의, 법원사무관 ○○○) 또는 의견청취 보고서[전산양식 A1940-1, B2302]를 작성하여 기록에 편철하는 방식으로 의견 청취 사실을 표시하여야 한다(전문심리예규 4조 2항).

한쪽 당사자가 지정에 반대하는 경우 그 반대의견을 검토하여 그것이 합리적인 경우 다른 후보자를 물색하는 것이 타당하고, 근거 없이 거부 태도를 나타내는 것에 불과할 경우에는 해당 후보자를 전문심리위원으로 지정할 수 있다고 봄이 타당하다. 양쪽 당사자 모두 전문심리위원 참여의 필요성에 대하여 부정적인 의견을 보인 경우 일단 당사자에게 그 필요성에 대하여 설득할 필요가 있을 것이나, 양 당사자 모두 부정적 의견을 유지할 경우 당사자가 합의에 의하여 전문심리위원 참여결정을 취소하여 달라고 신청하면 참여결정을 필요적으로 취소하여야 하는 점에 비추어 참여결정을 하지 않는 것이 타당하다.

당사자 의견 청취 후 특별한 사정이 없으면 해당 후보자를 전문심리위원으로 지정하여 참여하게 하는 전문심리위원 참여결정을 한다. 전문심리위원 참여결정[전산양식 A1941]은 반드시 송달에 의하여 고지할 필요는 없고 상당한 방법으로 고지함으로써 효력이 생긴다(민소 221조 1항). 결정 원본의 작성 이 필수적인 것은 아니고 조서에 기재하는 방식으로 행하는 것도 가능하다(154조 5호). 송달방식에 의하여 고지하는 경우에는 결정 등본 등을 송달하면 된다(178조).

전문심리위원의 수는 각 사건마다 1인 이상으로 되어 있으므로(민소 164

조의4 1항), 필요에 따라 복수의 전문심리위원을 지정할 수 있다. 예를 들면, 의료사건 쟁점 해명 등을 위하여 신경외과와 정형외과의 전문가를 모두 필요로 하는 경우 등이 이에 해당할 것이다. 반드시 한 번에 복수의 전문심리위원을 지정하여야 하는 것은 아니고 동시 혹은 이시에 복수의 전문심리위원을 지정할 수 있다.

다. 전문심리위원의 소송절차 참여 형태

전문심리위원은 ① 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나, ② 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술하는 형태로 소송절차에 참여하게 된다(민소 164조의2 2항). ‘설명’은 전문심리위원의 판단을 배제한 객관적인 사항만을 말하는 것이고, ‘의견 진술’은 전문심리위원의 전문지식에 의하여 판단되는 내용까지 포함되는 것으로 볼 수 있다.

라. 전문심리위원의 구체적 참여 절차

(1) 기일 외 설명 등 요구와 조치

재판장이 기일 외에서 전문심리위원에게 설명 또는 의견을 요구할 경우 특별한 사정이 없으면 설명 등 요구서[전산양식 A1943, A1943-1, B2305]를 전자우편, 팩시밀리 등을 활용하여 보내는 방식으로 한다(전문심리예규 5조 2항). 이때 법원사무관 등으로 하여금 사안의 개요를 기재한 서면 또는 소송서류, 증거서류의 사본을 보내게 할 수 있다(5항).

재판장은 위 요구와 관련하여 질문의 내용, 질문의 순서 등에 관하여 전화, 전자우편, 팩시밀리 등을 활용하여 당사자와 사전에 협의할 수 있다(전문심리예규 5조 1항).

위와 같이 설명 등을 요구한 사항이 소송관계를 분명하게 하는 데 중요한 사항이라고 인정할 때는 법원사무관 등으로 하여금 설명 등 요구 통지서[전산양식 A1944, B2306]를 이용하여 그 사항을 양쪽 당사자에게 통지하게 하

여야 한다(전문심리예규 5조 3항). 소송관계를 분명하게 하는 데 중요한 사항이란 전문심리위원의 설명 등의 내용에 따라서 당사자의 공격방어방법에 관하여 중요한 변경이 생길 수 있는 사항으로서 전문심리위원이 실제 설명 등을 하기 전에 설명 등을 요구한 사항을 당사자에게 통지하는 것이 바람직하다고 판단되는 사항을 말한다. 법원사무관 등이 양쪽 당사자들에게 위 통지를 한 때는 설명 등 요구 통지서에 통지의 방법과 날짜를 적는 방식(예컨대 2025. ○. ○. 팩시밀리 통지, 법원사무관 ○○○)으로 통지사실을 표시하여야 한다(4항).

(2) 전문심리위원에 대한 준비 지시

재판장은 필요하다고 인정될 경우 전문심리위원에게 소송목적물 확인 등 적절한 준비를 지시할 수 있다(민소규 38조의5 1항). 이 경우 법원사무관 등으로 하여금 준비할 내용, 준비의 기한 등을 명시한 준비지시서[전산양식 A1946, B2308]를 전자우편, 팩시밀리 등으로 보내게 하거나 그 밖의 적절한 방법으로 준비를 지시할 수 있다(전문심리예규 7조 1항). 전문심리위원은 설명 등을 위하여 당사자의 주장을 파악하고 관련 전문지식을 확인하는 등의 조치를 하거나 나아가 필요한 경우 특수한 전문적 문헌을 조사하거나 건축 관계 소송에서 계쟁물인 건물의 하자 상황을 확인할 필요가 있을 것이다. 이러한 준비의 필요성 정도 등은 개별 사건 내지 심리 정도 등에 따라 달라지게 될 것이므로 재판장이 판단하여 그 준비를 지시할 수 있도록 한 것이다.

법원사무관 등은 양쪽 당사자에게 준비 지시 통지서를 전자우편, 팩시밀리 등으로 보내거나 그 밖의 적절한 방법으로 준비 지시의 취지를 통지하여야 한다(민소규 38조의5 2항, 전문심리예규 7조 2항). 법원사무관 등은 준비 지시 통지서에 통지의 방법과 날짜를 적는 방식 또는 준비 지시 통지 보고서[전산양식 A1947-1, B2310]를 작성하여 기록에 편철하는 방식으로 통지사실을 표시하여야 한다(전문심리예규 7조 3항).

(3) 전문심리위원의 기록 열람

전문심리위원이 특정 사건의 전문심리위원으로 지정되면, 전문심리위원 아이디와 공인인증서로 전자소송포털(<https://ecfs.scourt.go.kr>)에 로그인 후 전자소송포털 상단 ‘나의 전자소송’ > ‘나의사건열람’ 메뉴에서 열람이 가능하다. 다만 지정된 전문심리위원이 전자소송포털 이용이 불가능한 경우에는 해당 재판부에서 기록을 출력·복사하여 제공하고 있다. 해당 사건 변론 종결 시 또는 해당 사건 종국 시 전문심리위원의 열람 권한은 제한된다.

상임전문심리위원의 경우 재판사무시스템을 이용하여 기록 열람을 할 수도 있다. 이를 위해서는 해당 재판부에서 재판사무시스템 메뉴(SMK203_01 기록권한관리)를 통하여 상임전문심리위원에게 기록 열람 권한을 부여하여야 한다. 이때 해당 재판부는 상임전문심리위원에게 사건 기록 전체에 대하여 열람권한을 부여하거나 또는 특정문서에 한정하여 열람권한을 부여할 수 있고, 전문심리위원 참여결정 이전이라도 상임전문심리위원에게 기록 열람 권한을 부여할 수도 있다.

(4) 전문심리위원의 서면 제출 및 기일 출석 진술 등

전문심리위원은 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다(민소 164조의2 2항).

전문심리위원으로 하여금 재판기일에 출석하여 설명 등을 진술하게 할 때에는 법원사무관 등은 재판기일의 1주일 전까지 전문심리위원에게 전화, 전자우편, 팩시밀리 등 적절한 방법으로 기일을 통지하여야 한다. 재판장은 위 기일통지를 하면서 사안의 개요를 기재한 서면 또는 소송서류, 증거서류의 사본을 보내게 할 수 있다(전문심리예규 6조).

(5) 좌석의 위치 및 조서의 기재 등

전문심리위원의 법정에서의 좌석 위치는 법대 중앙을 향하여 왼쪽의 당사자 좌석 앞에서 법대 중앙을 향하게 하고, 전문심리위원이 법정 외에서 참여할 경우 법관과 가까운 적당한 곳에 위치한다. 재판장은 법정의 구조 등을

고려하여 전문심리위원 좌석의 위치 및 방향을 달리 정할 수 있다(전문심리예규 8조).

전문심리위원이 기일에 참여한 때에는 조서에 그 성명을 기재하고, 전문심리위원이 재판장 등의 허가를 받아 소송관계인에게 질문한 때에는 조서에 그 취지를 기재하여야 한다(민소규 38조의7). 전문심리위원의 설명 등은 증거자료가 되지 아니하므로 전문심리위원의 설명 등을 조서에 반드시 기재하여야 하는 것은 아니다. 전문심리위원의 설명 등의 내용을 기재할 것인지, 어느 정도 기재할 것인지는 개별 사건별로 개별적으로 판단하여야 한다.

(6) 당사자의 의견진술 기회

전문심리위원이 설명 등을 기재한 서면을 제출한 경우에는 법원사무관 등은 양쪽 당사자에게 그 사본을 보내야 한다(민소규 38조의4). 법원은 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 등의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술 기회를 주어야 한다(민소 164조의2 4항). 이는 전문심리위원의 설명 등을 살펴 검증할 기회를 부여하고 전문심리위원이 참여하는 절차의 투명성을 높이기 위한 것이다.

(7) 전문심리위원의 설명 또는 의견의 허용한계

전문심리위원은 소송절차에서 법원의 보조자로서 역할을 하는 것이므로, 원칙적으로 당사자의 주장과 제출된 증거를 전제로 하여 문제가 되는 특정 사항에 대하여 전문지식에 근거하여 설명 등을 하면 되는 것이고, 당사자가 주장하고 있지 않고, 법원도 설명 내지 의견을 요구하지 않은 사항에 대해서 직접적으로 설명 또는 의견을 진술하는 것은 적절하지 않다. 법원은 전문심리위원이 설명 등을 진술하기 전에 위와 같은 점에 유의하도록 주의를 환기할 필요가 있다. 다만 전문심리위원이 참여하는 절차의 단계에 따라 그 한계는 다소 달라질 여지는 있다.

재판의 합의에는 참여할 수 없다(민소 164조의2 2항 단서).

마. 소송절차 진행 단계에 따른 구체적 역할

(1) 쟁점정리 단계

전문심리위원은 쟁점이 되는 사실관계 등의 이해를 위하여 필요한 설명 등을 함으로써 논의를 실질적으로 진전시켜 효율적인 쟁점정리를 할 수 있게 한다. 주장정리, 증인신문사항의 정리, 감정사항의 정리, 증인신문 내지 감정을 실시하는 시기 결정 등을 위해서 전문심리위원의 설명 등이 필요할 수 있다. 당사자들은 전문심리위원의 설명 등을 토대로 주장 내지 증명을 보강, 검토, 변경 등의 조치를 취할 수 있게 되고, 법원은 전문심리위원의 설명 등을 토대로 당사자들에게 적절히 석명권을 행사할 수도 있게 된다.

다만 앞서 본 바와 같이 전문심리위원이 당사자가 주장하고 있지 않고, 법원도 설명 내지 의견을 요구하지 않은 사항에 대해서 직접적으로 설명 또는 의견을 진술하는 것은 적절하지 않으며, 법원도 전문심리위원에게 그와 같은 점을 유의하도록 주의를 줄 필요가 있다.

(2) 증거조사 단계

전문심리위원은 증거조사 단계인 증인신문기일, 감정인신문기일 등에도 참여할 수 있다. 증거조사 단계에서 소송관계를 분명하게 한다는 것은 증언 등에 나타난 전문용어의 의미를 명확히 하는 것, 당사자의 주장과 증언 등의 취지와의 관계를 분명히 하는 것, 감정서의 내용을 명확히 설명하는 것 등이 그에 해당할 것이다.

전문심리위원은 기일에 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문을 할 수 있다(민소 164조의2 3항). 이와 같이 전문심리위원이 증인 등에게 직접 질문하는 것은 예외적인 경우에 인정되어야 하고, 일반적으로 전문심리위원의 설명 등을 듣고 심증형성의 주체인 법원이 증인 등에 질문을 한다.

재판장은 전문심리위원의 말이 증인의 증언에 영향을 미치지 않게 하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 증인의

퇴정 등 적절한 조치를 취할 수 있다(민소규 38조의6). 다만 위 조항은 당사자 본인신문, 감정인신문에는 적용되지 않는다.

(3) 화해 단계

증거조사를 마치고 심리가 상당히 성숙된 단계에서 전문적인 사실관계에 관한 견해의 차이를 좁히면서 화해적 해결을 모색할 필요가 있는 사건이 적지 않다. 화해의 전제가 되는 사실관계 등을 정리하기 위하여 전문심리위원의 전문적 지식이 필요할 때, 적절한 화해조항 작성, 분쟁의 일괄 해결 등을 위하여 전문적 지식이 필요할 때(예컨대 의료소송, 건설소송 등 관련하여 향후치료비, 하자보수비 추산 등이 필요한 경우) 등이 이에 해당할 것이다.

3. 전문심리위원의 설명, 의견 진술의 소송상 취급

가. 증거자료 해당 여부

전문심리위원의 설명이나 의견 진술은 단순히 법관이나 소송관계인의 이해를 돕기 위한 사실상 진술에 불과하고 사실인정의 자료나 증거자료가 될 수 없다(대법원 2014. 12. 24. 선고 2013다18332 판결, 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다16527 판결).

전문심리위원의 설명 등으로 감정을 대체하는 것은 허용되지 않는다. 다만 소액사건 등 소가가 크지 않으나 고액의 감정비용이 소요되는 사안에서 전문심리위원을 활용하여 조기에 화해·조정을 유도하거나 전문심리위원의 설명 등을 참작하여 사건을 해결하는 것은 가능할 것이다.

감정 가능성, 감정신청의 적정성 여부를 판단하고 감정사항을 확정하기 위하여 전문심리위원의 설명을 참고하거나 이미 감정 결과가 제출된 사건에서 재감정, 감정보완 또는 사실조회신청 등이 있는 경우 전문심리위원으로 하여금 기존 감정서를 분석·검토하도록 하여 꼭 필요한 사항에 한하여 재감정 등이 이루어지도록 하는 것 역시 전문심리위원에 의한 감정 제도 보완의 좋은 예이며, 감정료를 결정하는 단계에서도 전문심리위원을 활용하여 감정

로 산정근거의 적정성 등을 검증할 수도 있을 것이다. 이러한 필요성에 부응하여 전문심리위원규칙(2조의4, 2조의5, 2025. 1. 1. 시행)을 개정하여 상임전문심리위원을 겸하면서 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행하는 감정관리위원 제도를 도입하였다.

나. 변론 전체의 취지에 포함되는지 여부

자유심증주의에 따라 변론 전체의 취지로 참작하는 것은 가능하다는 것이 실무이나, 이를 긍정할 경우 법관 스스로가 당사자에게 한 질문이나 설명, 법관이 다른 법관에게 한 설명도 변론 전체의 취지에 포함시킬 수가 있다는 말과 다를 바가 없어 타당하지 않다는 취지로 반대하는 견해도 있다.

4. 전문심리위원에 대한 대우

전문심리위원에게는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 수당이 지급되고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다(민소 164조의4 2항).

전문심리위원에 대한 수당은 전문심리위원으로 지정되어 소송절차에 참여한 전문심리위원에게 지급하는데, 전문심리위원으로서 소송절차에 참여하기 전에 참여결정이 취소되거나 소가 취하되는 등으로 소송절차에 참여하지 아니한 전문심리위원이 소송절차에 참여하기 위한 서면을 작성하는 등 준비를 한 경우에는 당해 재판장의 재량에 의하여 수당을 지급할 수 있다(전문심리예규 9조 1항). 수당은 소송이 종료된 후 지체 없이 지급하되, 종료되기 이전이라도 전문심리위원이 더 이상 참여할 필요가 없다고 인정하는 때에는 수당을 지급하게 할 수 있다(2항). 수당을 지급하기 전에 전문심리위원으로부터 계좌번호 신고서[전산양식 A1961, B2315]를 제출받는다(3항).

재판장은 사안의 난이, 전문심리위원이 수행한 직무의 내용, 소송절차 참여에 소요된 시간 등을 참작하여 전문심리위원의 수당을 증액할 필요가 있

다고 인정한 때에는 대법관회의에서 매년 정한 기본 수당액의 5배 범위 안에서 수당을 증액할 수 있고, 증액할 경우 전문심리위원에게 수당을 증액함에 필요한 사유의 소명을 요구할 수 있다(전문심리예규 10조). 구체적인 증액 또는 감액기준은 전문심리위원의 소송절차 참여에 관한 예규 11조에 규정되어 있다.

전문심리위원에게 지급되는 여비와 숙박료 기준은 전문심리위원규칙 4조 4, 5항에서 규정하고 있으며, 전문심리위원에 대한 수당, 일당, 여비 및 숙박료는 국고에서 지급하고, 소송비용에는 산입하지 아니한다(전심규 4조 6항).

5. 상임전문심리위원

가. 제도의 도입 및 취지

종래 전문심리위원 제도는 그 지정 및 참여를 위한 절차가 다소 번거로운 면이 있어서 활용도를 높이는 데 한계가 있었다. 그리하여 사건이 많은 특정 분야(의료, 건설 등)의 전문심리위원을 법원에 상근하게 함으로써 재판부와와의 접근성을 높이고, 다수 소송사건에서의 누적된 경험을 토대로 재판부의 수요에 더 부합하는 자문을 할 수 있도록 하기 위해서 2016. 11. 1. 전문심리위원규칙 개정을 통하여 상임전문심리위원 제도를 도입하게 되었다. 나아가 2025. 1. 1. 전문심리위원규칙 개정을 통하여 감정채부, 감정인 선정, 감정사항 검토, 감정인 업무 감독 등 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행할 감정관리위원 제도를 도입하였고, 상임전문심리위원이 감정관리위원을 겸할 수 있도록 하였다.

나. 상임전문심리위원 제도의 운용

(1) 전문심리위원제도와 동일

전문심리위원 지정과 참여의 절차 자체는 동일하다.

(2) 전문심리위원제도와 상이

상임전문심리위원은 법원행정처장이 위촉하고, 위촉기간은 2년으로 하되, 재위촉할 수 있다(전심규 2조의2 1항, 2항). 상임전문심리위원은 법원행정처장의 허가 없이 영리를 목적으로 하는 다른 직무를 겸할 수 없다(3항). 법원행정처장은 효율적인 업무처리를 위하여 필요하다고 판단하는 때에는 고등법원 또는 지방법원 법원장으로 하여금 상임전문심리위원에게 그 업무의 수행에 필요한 사무실 등 물적 시설을 제공하게 할 수 있고(4항), 법원은 상임전문심리위원이 소송절차에 참여한 때에는 매년 1회 이상 정기적으로 상임전문심리위원이 수행한 업무의 적정성을 평가하여야 한다(5항).

한편 위촉후보자의 선발 및 위촉 등에 관한 업무의 적정을 도모하기 위하여 의료, 건설 등 분야별로 상임전문심리위원 선발위원회를 둘 수 있다(전심규 2조의5).

상임전문심리위원에게는 급식수당, 교통지원수당, 자료조사 및 연구수당, 관리업무수당, 상임근무수당, 사건수당이 지급된다(전심규 4조 2항).

2025. 6. 1. 현재 전국 고등법원 단위로 의료, 건설 분야의 전문가 30명(서울고등법원 15명, 수원고등법원 4명, 대전고등법원, 부산고등법원 및 광주고등법원 각 3명, 대구고등법원 2명)이 상임전문심리위원으로 위촉되어 근무하면서 소송 초기단계에서부터 간편하게 전문심리위원 참여결정에 의하여 소송절차에 참여하고 있다. 상임전문심리위원은 기존 전문심리위원 직무 외에도 전문분야에 관한 일반적인 용어나 전문지식을 간이한 방법으로 설명함으로써 충실한 심리와 신속한 분쟁 해결에 도움을 주기도 한다.

다. 감정관리위원 제도의 도입

감정채부, 감정인 선정, 감정사항 검토, 감정인 업무 감독 등 전문심리위원의 업무 중 감정절차의 관리업무를 수행할 감정관리위원 제도를 도입하였다. 선발·위촉 방식, 겸직, 업무수행에 필요한 물적 시설의 제공 및 업무 평

가는 상임전문심리위원의 그것과 동일하다(전심규 2조의4). 감정관리위원은 재판장의 요구를 받아 감정인 등의 선정·재선정 또는 지정, 감정인등 후보자, 감정과목과 감정사항, 감정료 증감, 예상감정료산정서의 적정성, 감정료 산정서의 적정성 등에 관한 의견제시 업무를 수행하며 재판장의 지휘를 받아 감정인 평정 등에 관한 의견제출 업무를 수행한다(감정예규 9조 5항, 6항, 9조의2, 11조 3항, 4항, 15조 2항, 3항, 15조의2, 15조의3, 25조 1항 3호, 4호, 27조 2항, 42조 4항, 44조 5항, 46조 2항 각 신설).

아울러 감정관리위원의 원활한 업무수행을 지원하기 위하여 필요한 경우 각 고등법원에 감정관리센터를 설치하고(전심규 2조의7), 감정관리센터에 감정담당판사, 감정관리위원을 두도록 하였다(감정예규 51조 내지 53조 신설). 상임전문심리위원과 감정관리위원을 겸하는 경우에는 수당을 중복하여 지급하지 아니한다(전심규 4조 2항 단서).

감정관리위원의 소송절차 참여와 관련하여서는 제28장(감정·검증·사실조회) 제1절 참조.

제24장

전문심리위원
제도

제3절 전문심리위원 참여결정의 취소

1. 의의

전문심리위원 참여결정의 취소는 임의적 취소와 필요적 취소로 구별된다(민소 164조의3). 전문심리위원 참여에 관한 당사자들의 의사를 존중하고 제도에 대한 신뢰를 확보하기 위한 장치이다. 전문심리위원 참여결정은 직권이나 당사자의 신청으로 상당하다고 인정하는 때에 취소할 수 있다(임의적 취소). 그리고 당사자가 합의로 전문심리위원 참여결정 취소를 신청한 때에는 그 결정을 취소하여야 한다(필요적 취소).

2. 임의적 취소

당사자는 전문심리위원 참여결정에 대하여 취소신청을 할 수 있다(민소 164조의3 1항). 기일에서 말로 하는 경우를 제외하고는 서면으로 하여야 하고, 그 신청이유를 밝혀야 한다(민소규 38조의8). 신청을 원칙적으로 서면으로 하게 하는 것은 절차를 명확하게 하기 위한 것이다. 전문심리위원 참여결정은 법원이 직권으로 결정할 성질의 것이므로 참여결정의 취소를 구하는 당사자 신청 역시 법원의 직권발동을 촉구하는 것이라고 봄이 타당하다. 참여결정을 취소하는 것이 상당한지 여부는 전문심리위원을 소송절차에 참여하게 할 필요성이나 상당성이 소멸되었는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

민사소송법 164조의2는 ‘전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게’라고 규정하여 지정과 참여를 분리하지 않고 하나의 결정을 하도록 하고 있으므로 지정결정에 대해서만 취소를 구할 수는 없다고 본다. 따라서 당사자가 특정 전문심리위원을 다른 전문심리위원으로 변경해 줄 것을 희망하고 있고 법원이 다른 전문심리위원의 참여 필요성을 인정하는 경우 전문심리위원 지정만을 취소할 수는 없고, 전문심리위원 참여결정을 취소하고 다시 전문심리위원 후보자를 물색하여 새로운 전문심리위원을 지정하여 참여하게 하는 결정을 해야 할 것이다.

3. 필요적 취소

당사자가 합의로 참여결정의 취소를 신청하는 때에는 법원은 필요적으로 그 결정을 취소하여야 한다(민소 164조의3 2항). 당사자의 절차에 대한 의사결정을 보장하려는 취지이다.

임의적 취소의 경우와 달리 신청의 이유를 명시할 필요가 없다(민소규 38조의8 2항 단서). 취소신청 이유에 대한 당부를 판단할 필요도 없이 참여결정을 취소하여야 하는 것이므로 이유를 명시하게 할 필요가 없기 때문이다.

한쪽 당사자가 전문심리위원 참여결정에 대한 취소신청을 한 경우에 법원

으로서는 상대방의 의견을 들어볼 수도 있다. 이때 상대방도 그 참여결정의 취소를 신청하면 참여결정의 취소는 필요한 것이 된다.

제4절 전문심리위원의 제척 및 기피

1. 서설

전문심리위원의 중립성·공평성을 확보하기 위하여 법관의 제척, 기피에 관한 규정을 준용한다(민소 164조의5 1항, 41조 내지 45조, 47조). 전문심리위원은 법관의 직권을 보충하기 위해 전문지식과 경험을 바탕으로 법원에 대하여 설명 등을 하게 되므로 전문심리위원의 공평성 및 중립성을 확보하는 것이 반드시 필요하다.

2. 전문심리위원의 제척

전문심리위원은 사건이나 당사자와의 사이에 민사소송법 41조 1항에서 열거하고 있는 사유에 준하는 원인이 있는 경우에 직무집행에서 제척된다. 제척이란 일정한 원인이 있는 때에 법률상 당연히 직무에서 배제되는 것을 말한다. 전문심리위원이 제척의 원인을 알았는지 여부는 묻지 않는다.

전문심리위원이 사건에 관하여 감정을 하였을 때가 제척 원인에 해당한다는 점을 유의하여야 한다. 전문심리위원이 그 사건에 관하여 조정위원이 되었던 적이 있는 것은 이전심급의 재판에 참여한 것이 아니다. 조정위원회는 합의형 해결을 위하여 조정 활동을 하지만 종국적·확정적 판단을 하는 것이 아니므로, 이전심급의 재판에 참여하였다고 할 실질이 없다고 보아야 한다.

법원은 제척의 이유가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 한다(민소 42조). 제척의 재판의 성질은 확인적 재판이고 형성적 재판은 아니다.

3. 전문심리위원의 기피

전문심리위원에게 제척 원인 외에 공정한 직무집행을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 당사자는 그 전문심리위원을 기피할 수 있다(민소 43조 1항). 공정한 직무집행을 기대하기 어려운 사정은, 건전한 상식을 가진 일반인의 판단할 때 전문심리위원과 사건 및 사건 당사자와의 관계로 보아 전문심리위원의 설명 등이 편파·불공정한 것이 될 것이라는 의혹을 갖는 것이 합리적이라고 인정될 만한 객관적인 사정을 의미한다. 사건 당사자와 전문심리위원이 대학동창이고 연구실도 같으며 매우 친한 경우, 전문심리위원이 그 사건에서 다투어지고 있는 사안에 대하여 관계가 있고 소송의 결과에 따라서는 당사자가 책임을 물을 수 있는 경우 등이 이에 해당한다.

공정한 직무집행을 기대하기 어려운 사정은 전문심리위원과 사건의 관계에서 나오는 사정이므로 구체적 사건과 직접 관련이 없는 전문심리위원의 행실, 사상, 해당 전문분야에서의 학문적 입장 등은 이에 해당하지 않는다. 공정한 직무집행을 하기 어려운 사정은 객관적 사정이므로 전문심리위원의 전문적 분야에서의 입장 등에 비추어 자신의 주장과 다른 설명을 할 것 같다는 주관적 불만은 여기에 해당하지 않는다.

전문심리위원은 법관의 지시에 따라 절차에 참여하게 된다. 전문심리위원이 법관의 지시에 따르지 않기 때문에 절차참여의 수단이 불공정하게 되는 것과 같은 경우에는 전문심리위원으로서의 적격성에 의심이 생기게 될 것이나, 그 경우 법관은 직권으로 전문심리위원 지정을 취소할 수 있으므로(민소 164조의3 1항), 이를 기피사유로 구성할 필요성은 크지 않다.

기피신청권자는 당사자에 한정된다. 당사자가 전문심리위원을 기피할 이유가 있다는 것을 알면서도 전문심리위원이 참여한 변론기일에서 본안에 관하여 변론을 하거나 변론준비기일에서 진술을 한 때에는 그 전문심리위원을 기피할 수 없다(민소 43조 2항). 이는 당사자가 전문심리위원에게 문제가 되는 사정이 있다는 것을 알면서 해당 전문심리위원이 참여한 절차에서 소송

활동을 한 때에는 기피신청을 포기한 것으로 해석되기 때문이다. 따라서 당사자가 전문심리위원에게 기피의 원인이 있는 것을 몰랐거나 기피의 원인이 그 후에 생긴 때에는 기피신청을 할 수 있다. 기피의 원인을 모른 것에 대하여 당사자에게 과실이 있어도 마찬가지이다.

4. 제척 또는 기피 재판과 절차

전문심리위원에 대한 제척, 기피와 관련하여 민사소송법 46조가 준용되지 않으므로, 전문심리위원의 제척 또는 기피 재판은 해당 사건이 합의부 사건인 경우에는 그 합의부가, 단독 사건인 경우에는 그 단독판사가 결정으로 한다. 위 재판은 공익적 성격을 가지고 있으므로, 법원이 증명에 따라 재판을 하고 의심스러운 경우 직권으로 증거조사를 해야 한다.

합의부 사건에 참여하고 있는 전문심리위원에 대한 제척, 기피는 그 합의부에, 단독 사건에 참여하고 있는 전문심리위원에 대한 제척 또는 기피는 해당 단독판사에게 이유를 밝혀 신청하여야 하고, 제척 또는 기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날로부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다(민소 44조). 제척 또는 기피신청을 받은 전문심리위원은 당해 제척 또는 기피신청에 대하여 의견을 진술할 수 있다(164조의5 2항 2문). 의견진술에 관하여 위와 같은 특칙을 두고 있으므로, 제척 또는 기피를 당한 법관의 의견서 제출과 관련된 민사소송법 45조 2항은 준용되지 않는다고 보아야 한다.

제척 또는 기피신청이 위 방식에 어긋나거나 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우에는 신청을 받은 법원 또는 법관은 결정으로 이를 각하한다(민소 45조).

제척 또는 기피신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대해서는 불복할 수 없다(민소 47조 1항). 제척 또는 기피신청에 대한 각하결정 또는 제척 또는 기피신청이 이유 없다는 결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(2항). 즉시항고는 재판이 고지된 날로부터 1주 이내에 하여야 한다(444조). 각하결정에

대한 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 아니한다(47조 3항).

제척 또는 기피신청이 있는 때에는 해당 전문심리위원은 그 신청에 관한 결정이 확정될 때까지 그 신청이 있는 사건의 소송절차에 참여할 수 없다(민소 164조의5 2항 1문). 법원은 그사이에 전문심리위원이 참여할 필요가 없는 절차를 진행시킬 수 있다.

제척 또는 기피에 이유가 있다는 결정이 있으면, 해당 전문심리위원은 절차에서 배제된다. 제척 또는 기피에 이유가 없다는 결정에 대하여 즉시항고가 된 경우에도 결정이 확정되지 않았으므로 해당 전문심리위원은 절차에 참여할 수 없다.

법관의 회피에 관한 민사소송법 49조는 전문심리위원에 대하여 준용되지 않는다.

제5절 수명법관 등의 권한, 비밀누설죄 등

1. 수명법관 등의 권한

가. 서설

전문심리위원을 소송절차에 참여하게 하는 절차에서 수명법관 또는 수탁판사는 법원 및 재판장의 직무 중 일부를 행한다(민소 164조의6).

다만 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 하는 결정, 전문심리위원 참여 결정의 취소결정은 수소법원의 권한으로 남아 있다. 전문심리위원 참여결정이 소송절차에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려한 것이다.

나. 수명법관 등의 권한

수명법관 등은 ① 전문심리위원이 소송절차에서 설명 또는 의견을 기한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술하는 절차에 관한

지휘권(민소 164조의2 2항), ② 전문심리위원이 기일에서 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 질문하는 것에 대한 허가(3항), ③ 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주는 것(4항), ④ 전문심리위원에 대한 준비지시(민소규 38조의9, 38조의5), ⑤ 전문심리위원의 말이 증인의 증언에 영향을 미치지 않게 하기 위하여 증인의 퇴정 등 적절한 조치를 취하는 것(38조의9, 38조의6), ⑥ 조서의 기재에 관한 재판장의 직무(38조의9, 38조의7)에 관하여 법원 또는 재판장과 동일한 권한을 가진다.

2. 비밀누설죄

가. 서설

전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.

전문심리위원으로서 소송절차에 참여하게 되면 당사자 등 다른 사람의 비밀을 알게 될 수도 있다. 공무원 또는 공무원이었던 자가 법령에 의한 직무상 비밀을 누설할 때에는 공무상비밀누설죄(형법 127조)로 처벌된다. 전문심리위원은의 경우 공무원은 아니지만 소송절차에 참여하는 과정에서 알게 된 당사자 등 다른 사람의 비밀을 누설하지 못하도록 한 것이다.

나. 구성요건 등

직무수행 중 알게 된 비밀이란 전문심리위원으로서의 직무를 수행하는 과정에서 알게 된 것으로서 일반적으로 알려져 있지 아니한 사항을 말한다. 누설이란 비밀사항을 제3자에게 알리는 것을 말한다. 알리는 방법에는 제한이 없다.

3. 벌칙 적용에서의 공무원 의제

전문심리위원은 공무원은 아니지만 공무원과 같이 공평성·중립성을 지켜야 하므로, 이를 담보하기 위하여 수뢰, 사전수뢰(형법 129조), 제3자 뇌물제공(제130조), 수뢰 후 부정처사, 사후수뢰(131조), 알선수뢰(132조)의 벌칙적용에 관하여 전문심리위원을 공무원으로 보도록 규정하고 있다(민소 164조의8).